

1500193-13.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Quando menor ficou internado por tráfico e pelo art. 157. Trabalhava anteriormente como ajudante de caminhoneiro, mas em razão da pandemia, ficou sem serviço. Afirmou que por necessidade passou a trabalhar no tráfico. É usuário de drogas (maconha).

O réu Wesley, na fase policial (fls. 07), negou a prática do crime. Falou que foi até o local, que sabia ser um ponto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500193-13.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500193-13.2022.8.26.0537 2022/000137

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CASTRO PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

DANIEL CASTRO PEREIRA e WESLEY BATISTA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 09:50 horas, na Rua Caviúna, n.º 566, Bairro Eldorado, agindo em concurso, unidos em desígnios com identidade de propósitos e divisão de tarefas para o fim comum, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, cocaína, "crack" e maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

As prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas por decisão do juiz de plantão (fls. 59/63), tendo sido reapreciadas em 27.04.22 (fls. 109/110) e em 21.07.22 (fls. 205), e mantidas.

Foi apresentada defesa prévia (fls. 103/104), sendo recebida a denúncia em 27.04.22 (fls. 109/110). Os réus foram interrogados no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça, nos debates orais, requereu a condenação dos acusados,

por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas; a aplicação da redução do art. 33 e regime aberto para o réu Daniel, que é primário (tem apenas processos em andamento); quanto ao acusado Wesley, duplamente reincidente, que seja afastada a redução do art. 33, § 4.º e fixado regime fechado, além do perdimento do dinheiro apreendido.

A Defensora Pública, em memoriais escritos (fls. 177/202), requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Em caso de eventual condenação dos réus, requereu a fixação das penas-base no mínimo legal e sem aumento pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, que em relação ao réu Daniel requereu sejam consideradas as atenuantes da confissão e da menoridade, redução do art. 33, § 4.º no máximo, fixação de regime aberto, com as substituições legais, por ser primário, e direito de recorrer em liberdade, e quanto ao réu Wesley pleiteou que, caso seja reconhecida a agravante da reincidência, o aumento no mínimo (1/6), aplicação da detração e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O acusado Daniel, fase policial (fls. 06), negou a prática do crime. Disse que estava no local para fumar um cigarro de maconha na companhia de Wesley, que é seu padrasto. Afirmou que as drogas apreendidas estavam com um homem, que as jogou em seus pés e se evadiu.

Em juízo, confessou a prática do crime, alegando que estava traficando junto com uma mulher. Os policiais os abordaram e queriam dinheiro. Disse que o corréu não tinha nada a ver, que é seu padrasto e foi buscar dinheiro para comprar mistura para casa. Falou que o corréu já estava indo embora. Informou que seus "patrões" diziam que tinham acerto com os policiais e achou que ia ser solto. Quando menor ficou internado por tráfico e pelo art. 157. Trabalhava anteriormente como ajudante de caminhoneiro, mas em razão da pandemia, ficou sem serviço. Afirmou que por necessidade passou a trabalhar no tráfico. É usuário de drogas (maconha).

O réu Wesley, na fase policial (fls. 07), negou a prática do crime. Falou que foi até o local, que sabia ser um ponto de tráfico, para fumar um cigarro de maconha. Disse que depois de ter comprado o cigarro de maconha, o traficante passou ao seu lado e disse "móio" (sic). Então, percebeu a aproximação dos policiais.

Contou que, mesmo "não devendo nada", por achar que seria preso, uma vez que estava em um ponto de venda de drogas, saiu correndo, sendo detido por um policial. Negou o tráfico, alegando que estava no local apenas para fumar um cigarro de maconha.

Afirmou que estava arrependido de ter tentado se evadir. Informou ter passagem criminal por roubo. Nunca traficou.

Em juízo, negou a prática do crime. Afirmou que é padrasto do corréu. Tinha dois meses que estava trabalhando, pediu dinheiro para o corréu para comprar cigarro. O corréu falou para ir mais tarde no ponto de tráfico pegar o dinheiro. Informou que foi pegar o dinheiro para comprar cigarro e para a mistura. Disse que o corréu deu R\$ 20,00 para ele. Andou uns 100 metros, quando viu os policiais apontando uma arma para o corréu e apreendendo com este uma sacola com drogas. Ficou parado olhando de longe, mas foi abordado pelos policiais. Tinha saído há 6 meses da cadeia, possuindo condenação por roubo, porte de arma e uso de drogas. É usuário de maconha e cigarro. Não estava com a sacola com drogas, apenas com R\$ 20,00 que o réu Daniel lhe deu. Estava no local errado e foi buscar dinheiro do crime. Não queria mais praticar crimes. Foi incriminado por ter passagem e dizer que era padrasto do réu Daniel. Pede uma oportunidade, porque ainda é novo, tem 27 anos. Não fugiu dos policiais, nem pulou muro, apenas ficou parado olhando de longe. Informou que tinha se machucado antes dos fatos, porque tinha caído do caminhão, ficou lesionado de leve e que às vezes doía. Falou que os policiais o levaram para o IML para demonstrar que não o agrediram.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 04/05), disseram que receberam a informação, via COPOM, que dois homens estavam traficando drogas na Rua Caviúna, n.º 566, sendo informadas as características físicas e as roupas que trajavam.

Relataram que se dirigiram ao local e se depararam com o acusado Daniel, cujas características e vestes correspondiam às informadas, e o abordaram. Afirmaram que encontraram invólucros de cocaína, "crack" e maconha e a quantia de R\$ 30,00 em

poder do acusado Daniel. Narraram que, enquanto abordavam o réu Daniel, viram o acusado Wesley, que estava um pouco mais a frente, arremessar uma sacola plástica no chão, empreender fuga e logo em seguida pular o muro de uma casa. Então, foram atrás do réu Wesley e o abordaram. Informaram que recolheram a sacola plástica dispensada pelo acusado Wesley e nesta localizaram diversos invólucros de drogas e a quantia de R\$20,00. Disseram que os acusados negaram a prática do crime. Esclareceram que não há escolas ou outras repartições instaladas próximas ao local dos fatos.

Amaro (policial), em juízo, narrou que o COPOM informou que havia dois homens traficando no local, fornecendo as características físicas e roupas. Afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico e foram para lá com mais duas viaturas. Disse que ele e seu parceiro avistaram os réus, um em cada ponto da viela, sendo que Daniel estava com uma bolsa, o corréu jogou uma sacola e saiu correndo. Foi atrás do réu Wesley e o pegaram na rua de baixo. Tanto na bolsa, quanto na sacola, havia porções de cocaína, maconha e "crack". Os réus negaram o tráfico e não havia outras pessoas no local. Não conhecia os réus anteriormente. Foi apreendido dinheiro em poder dos dois réus. Tem certeza que o réu Wesley dispensou a sacola e que foi a mesma pessoa detida. As características fornecidas pelo COPOM coincidiam com as dos réus.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Henrique. Narrou que tanto na sacola, quanto bolsa havia porções de drogas (maconha, cocaína e "crack"). Esclareceu que os réus negaram o tráfico, dizendo que apenas eram usuários, mas havia drogas em poder deles. Não havia mais pessoas no local. Informou que não conhecia os réus. Havia dinheiro com os dois réus.

O fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 19/20 - 86 porções de maconha, 45 invólucros de cocaína e 34 pedras de "crack") e a diversidade (maconha, "crack" e cocaína), que estavam divididas em invólucros, a apreensão de dinheiro, sendo que não provaram a sua procedência, a confissão judicial do réu Daniel, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fossem traficantes, posto que sequer demonstram possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A negativa dos réus (Wesley nas duas fases e Daniel na polícia) é desmentida pelos depoimentos uníssomos dos policiais nas duas fases, posto ambos estavam com bolsa e sacola contendo drogas, além de dinheiro, em local conhecido como ponto de tráfico, após denúncia anônima, cujas características e roupas coincidiam com as fornecidas pelo COPOM.

A confissão judicial do réu Daniel foi corroborada pelos depoimentos dos policiais, bem como pela apreensão de drogas e dinheiro em seu poder. Porém, a tentativa de inocentar o corréu está isolada nos autos, já que apreendidas drogas e dinheiro em poder deste.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que

denunciados pelas condutas de trazer consigo e guardar.

A materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 08/11) e laudo definitivo (fls. 159/162).

Assim, impõe-se a condenação dos acusados que segundo consta dos autos, o réu Wesley é reincidente (fls. 45 e 47 – proc. 26873-72.2015; fls. 45/46 – proc. 27872-59.2014) e o corréu Daniel é primário (fls. 147/151), possuindo apenas dois processos em andamento (fls. 137/138 e 140), que não podem ser considerados para quaisquer fins, em face do princípio do estado de inocência.

Quanto à alegação do réu Daniel de que os policiais pediram dinheiro nada há nos autos a corroborá-la, nem mesmo o corréu fez tal afirmação.

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que “a lei regulará a individualização da pena” e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

“O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)”.
Assim, a reincidência do acusado Wesley será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o réu Wesley, em razão da quantidade média de drogas (já que, nesta comarca, pequena quantidade é inferior a 100 porções), em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Aumento a pena de 1/6 em razão da reincidência.

O réu Wesley não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, “b” e “c” só se aplicam regimes mais brandos ao “condenado não reincidente”. As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente por roubo (fls. 45 e 47 – proc. 26873-72.2015) e porte ilegal de arma (fls. 45/46 – proc. 27872-59.2014), o que denota personalidade voltada para a prática de crimes, os quais são seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou “sursis” diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, “Lex specialis derogat generali” (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 27.01.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 16.10.24).

Por outro lado, “ad argumentandum”, ainda que se considere a detração conforme

entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), bem como pela quantidade de drogas apreendidas e tentativa de fuga, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Quanto ao réu Daniel, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face de sua situação econômica. Deixo de diminuir a pena pela menoridade e pela confissão judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (86 porções de maconha, 45 invólucros de cocaína e 34 pedras de "crack") já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de quilos, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º). Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena do réu Daniel será o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, diante da menoridade e confissão judicial, demonstrando arrependimento, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis e foi afastado pela jurisprudência do STF e do STJ o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO WESLLEY BATISTA DOS SANTOS à pena de 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, e DANIEL CASTRO PEREIRA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se acharem incursos no art. 33, "caput", do Código Penal.

Tendo em vista que o réu Wesley foi preso em flagrante, que o M.P não concordou com sua soltura, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 82/85) e decisão de fls. 205 que a manteve nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (reapreciação a cada 90 dias), e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra. Em relação ao réu Daniel, considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal), mas em razão da detração penal deverá ser abatido o tempo que ficou preso.

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, § 3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

O acusado Daniel poderá recorrer em liberdade, porque é primário e após as

substituições legais foram impostas apenas penas restritivas de direitos e multa. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por serem beneficiários da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 19 e 164/165), conforme prova produzida, é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 64), providencie-se o necessário quanto ao perdimento do dinheiro, comunicando-se ao SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e efetuem-se os cálculos das multas, abrindo-se vista às partes.

P.I.C.

Diadema, 12 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA